

1501080-07.2021.8.26.0545

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

Comarca: Atibaia

Foro: Foro de Atibaia

Vara: 1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Data de Disponibilização: 11/03/2022

... a sacola no chão e a pegou, negando o tráfico; indagado sobre o que a pessoa que levou à viatura falou, respondeu que tal indivíduo afirmou que havia ido buscar droga e que o cidadão abordado por seu parceiro estava efetuando o tráfico de drogas no local; indagado sobre como chegaram em tal indivíduo e se o viram comprando alguma coisa, respondeu que eles estavam próximos, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Atibaia

Foro de Atibaia

1ª Vara Criminal Infância e Juventude

Rua Doutor José Roberto Paim, 99, Atibaia - SP - cep 12945-007

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às19h00min

1501080-07.2021.8.26.0545 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1501080-07.2021.8.26.0545

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

EDVAN DE BRITO FARIAS

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Roberta Layaun Chiappeta de Moraes Barros

EDVAN DE BRITO FARIAS, vulgo "Neguinho", qualificado nos autos, foi denunciado como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea "j" (calamidade pública) do Código Penal porque, conforme denúncia oferecida pelo Ministério Público, no dia 06 de outubro de 2021, por volta das 03 horas, na vigência de Estado de Calamidade Pública em razão da pandemia de Covid-19, na Rua Newman, 100, Caetetuba, em Atibaia, trazia consigo e expunha à venda, para fins de tráfico ilícito, 67 porções de maconha, 102 de cocaína e 24 pedras de crack, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Nos termos da denúncia, o réu trazia consigo dentro de uma sacola e expunha à venda a um usuário as drogas acima indicadas, na mencionada via pública - que é notória por ser ponto de narcotráfico. Com efeito, logo que avistou policiais que patrulhavam a região, saiu correndo, assim como o fez o usuário.

A exordial narrou que tal atitude chamou a atenção dos agentes da lei, os quais foram ao encalço de ambos. Durante a perseguição do réu, foi possível ver que ele arremessou uma sacola. Ato contínuo, os policiais conseguiram abordá-lo e recuperaram a referida sacola, dentro da qual, além dos entorpecentes, havia a

quantia de R\$ 69,00. Indagado, EDVAN alegou ser mero usuário e que só pegou a sacola porque esta estava perto dele.

De acordo com a inicial, os agentes também conseguiram abordar o outro indivíduo, sendo que nada de ilícito acharam em poder dele. Na ocasião, ele disse que estava no local para comprar drogas com o réu.

Réu preso em flagrante, sendo sua prisão convertida em preventiva em audiência de custódia (fls. 50/55). A denúncia (fls. 97/99) foi oferecida e o réu foi notificado (fls. 111), tendo apresentado defesa preliminar (fls. 118/119), afastada por decisão que recebeu a denúncia (fls. 120/123). O réu foi citado (fls. 173). Durante a instrução, foram ouvidas três testemunhas, sendo o réu interrogado ao final (fls. 180/181).

Em memoriais, a representante do Ministério Público requereu a procedência da ação penal, entendendo provados os fatos narrados na denúncia (fls. 182/187).

A defesa argumentou, em síntese, que o réu confessou ser usuário de drogas, que veio de Extrema para Atibaia devido a um desentendimento com a esposa e, com R\$ 320,00 no bolso, decidiu beber num bar, sendo que por volta das 3h foi a uma biqueira comprar drogas, tendo adquirido 24 pedras de crack, o que lhe deixou com apenas R\$ 69,00. Alegou que quando estava em posse dos entorpecentes, foi abordado pelos policiais. Após realizar breve apanhado acerca dos depoimentos colhidos, a defesa entendeu que a acusação não foi capaz de produzir nenhuma prova da suposta mercancia de entorpecentes e, ausente a demonstração de tal elemento típico, defendeu ser caso de absolvição do réu, com fundamento no artigo 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal, por restar comprovada a inexistência dos fatos narrados na denúncia, uma vez que as drogas eram destinadas ao consumo próprio, conforme confessou o réu. Requereu, ainda, absolvição por não existir provas de que o réu concorreu para a infração penal. Invocou o princípio da presunção da inocência e requereu, subsidiariamente, a desclassificação do delito pelo qual o réu foi denunciado para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06. Postulou o direito de o réu apresentar eventual recurso em liberdade, concessão dos benefícios da justiça gratuita e perdão da pena de multa ou sua aplicação em patamar mínimo (fls. 195/197).

É o relatório. Passo a decidir.

A ação penal é procedente.

A materialidade criminosa está consubstanciada no auto de prisão em flagrante (fls. 01), no boletim de ocorrência (fls. 09/12), no auto de exibição e apreensão (fls. 13/14), no auto de constatação preliminar de substância entorpecente (fls. 15/16), nas fotografias das drogas apreendidas (fls. 38/40), nos laudos de exames químico-toxicológicos (fls. 83/84, 86/87 e 89/90) e na prova oral produzida.

A autoria criminosa deve ser imputada ao réu que, interrogado extrajudicialmente (fls. 08), disse que é usuário de drogas e que estava no local dos fatos para comprar drogas para si próprio e para amigos.

Em juízo, o réu disse que havia acabado de sair da cadeia, pois havia sido preso em 2016 e saiu em maio de 2021; não estava mais mexendo com drogas; estava fazendo "bicos" com piscina e não morava mais em Atibaia; brigou com a mãe de sua filha em Minas Gerais e acabou vindo para Atibaia; é usuário de drogas e veio com cerca de R\$ 300,00; começou a "tomar" durante o dia e foi para a região do Santa Clara já de madrugada, buscando drogas para comprar, tendo sido informado a respeito de onde havia uma "biqueira"; foi até a "biqueira", mas ao entrar na viela, uma viatura branca apareceu; os policiais passaram correndo atrás de dois indivíduos; saiu em sentido contrário despreocupado, pois não estava vendendo, mas já havia pegado 24 pedras de crack; saiu andando no sentido ao campo do Santa Clara e lá estava um policial a pé; tomou a rua 04, sentido Centro, para ir embora com suas 24 pedras de crack; quando olhou para trás, o policial já veio com a arma em sua "cara" e deu ordem de prisão; não reagiu, tendo sentado e colocado as duas mãos para trás; o policial chamou outro agente pelo rádio, sendo que chegaram lhe espancando, com socos e pontapés em seu rosto; as drogas que estavam em seu poder eram as 24 porções de crack, sendo que possuía R\$ 69,00 em dinheiro; o restante das drogas não estavam em seu poder; indagado sobre onde estavam os demais entorpecentes, respondeu não saber, tendo afirmado que foram apresentadas na Delegacia; tinha

consigo apenas as 24 porções de crack, as quais havia acabado de pegar da mão dos dois indivíduos que estavam na viela; indagado a respeito de Wellington, respondeu que não o conhece; confrontado com o fato de referida testemunha ter dito que seu apelido era "Neguinho" e que sempre comprava drogas de sua pessoa, respondeu que seu apelido é "Maranhão", e não "Neguinho"; perguntado sobre quanto dinheiro tinha consigo, respondeu que, salvo engano, possuía R\$ 69,00, mas que o montante que possuía antes de ter comprado as 24 pedras de crack era de aproximadamente R\$ 320,00; indagado sobre o motivo pelo qual saiu de Minas Gerais para comprar drogas em Atibaia, respondeu que brigou com a mãe de sua filha, veio de ônibus de Extrema durante o dia, começou a beber e sentiu abstinência do uso de drogas; não comprou drogas em Extrema porque havia dado sua palavra à mãe de sua filha que não usaria mais drogas, pois para voltar a morar com ela após sair da cadeia, teve que parar de usar drogas e voltar a trabalhar; quando brigaram, falou a ela que viria para Atibaia; começou a beber e sofreu uma recaída; novamente indagado sobre o motivo pelo qual veio para Atibaia, respondeu que não queria fazer isso em frente à mãe de sua filha; indagado sobre o motivo pelo qual o dinheiro que estava em seu poder era trocado, respondeu que tinha bebido durante o dia e trocou o dinheiro; negou a prática do delito; é analfabeto, já foi processado e condenado por tráfico de drogas; ficou cinco anos e três meses preso.

A testemunha Wellington Garcia Doratiotto disse que nesse dia, foi pego pela polícia; não conhece o rapaz que foi preso e afirmou que foi obrigado, pelos dois policiais que o pegaram no dia, a dizer o que disse na Delegacia; afirmou que não havia tanta gente no local e confirmou que tinha ido buscar droga, pois é usuário; naquele momento, entretanto, não havia ninguém no local; uma viatura com um único policial vinha vindo, sendo que este policial o abordou e o colocou dentro da viatura; o rapaz que foi preso, o qual insistiu não conhecer, estava em outro lugar, com outro policial, que estava a pé; não pode dizer que pegou alguma coisa com o indivíduo que foi preso, porque não pegou nada com ele; o policial estava com o indivíduo que foi preso na Reciclagem; quatro ruas acima, há uma "loja", onde foi abordado, sendo que lhe perguntaram onde estava indo, ao que respondeu que estava indo buscar uma porção de crack; foi colocado dentro da viatura e o policial lhe disse que iria à Delegacia e que deveria ser testemunha, dizer que pegou droga com o rapaz que foi detido e que ele é vendedor de droga; indagado se os policiais saíram quatro ruas acima para procurar alguém para incriminar o réu, respondeu que com certeza é isso, não sabendo dizer se os policiais saíram atrás de qualquer pessoa, confirmando, entretanto, que foi abordado e pego; disse que todos os policiais o conhecem, porque antigamente mexia com o tráfico de drogas; indagado sobre quem estava na sala ao ser ouvido na Delegacia, respondeu que só tinha o rapaz do computador; questionado, então, se poderia ter apresentado a versão que quisesse, uma vez que não havia policial algum lá, afirmou que estavam os dois policiais e o rapaz do computador; confrontado com o fato de ter dito que só havia o rapaz do computador, novamente advertido a respeito de sua responsabilidade como testemunha e dada nova oportunidade para falar o que aconteceu naquele dia, respondeu que acabou de dizer que está sendo verdadeiro.

A testemunha Carlos Alberto de Campos Junior, policial militar, disse que faziam patrulhamento pelo Jardim Santa Clara, no bairro Caetetuba, na rua Newman com a rua 02, onde avistaram dois indivíduos; desembarcou da viatura e realizou a abordagem num indivíduo, que era usuário de entorpecente; seu parceiro de viatura foi tentar realizar a abordagem no outro indivíduo, que se evadiu correndo por cerca de 200 metros; seu parceiro conseguiu realizar a abordagem; indagado sobre a distância que o indivíduo que abordou estava do outro indivíduo que fugiu, respondeu que eles estavam de cinco a dez metros próximos um do outro; fez a busca pessoal no indivíduo que abordou, colocou-o na viatura e foi atrás de seu parceiro, que se encontrava ao solo com o rapaz que ele havia abordado; no chão, havia várias porções de maconha, crack e cocaína jogadas; foi informado por seu parceiro que o indivíduo, durante a abordagem, chegou a jogar uma sacola de drogas; havia um pouco de dinheiro também; seu parceiro usou de força moderada para contê-lo; o réu foi algemado; solicitado a esclarecer a respeito da droga jogada no chão ou na sacola, explicou que quando chegou onde seu parceiro estava, viu ele ao solo, segurando o

indivíduo e tinha algumas porções de drogas espalhadas, próximas a eles; seu parceiro lhe disse que o indivíduo havia jogado a sacola de drogas no chão, a qual estourou, espalhando as porções no solo; confirmou que a sacola estava no local, assim como as drogas espalhadas no chão; esclareceu que o local em que o réu foi abordado é um terreno onde ficam usuários; explicou que provavelmente o réu dispensou a sacola e ela estourou, sendo que ao chegar, viu as porções de drogas caídas ao solo; indagado se a sacola não estava com o réu, e sim no solo, respondeu não poder afirmar, pois quando chegou, o cenário era esse que esclareceu; ao chegar no local, perguntou ao seu parceiro, que afirmou que a sacola em questão estava com o réu e que ele havia dispensado a sacola, a qual, segundo acredita, se abriu, espalhando drogas ao solo; indagado se a sacola estava com o réu antes de ele dispensar, respondeu positivamente; já abordou o réu algumas vezes; o réu, ao que se recorda, disse que era apenas usuário, que encontrou a sacola no chão e a pegou, negando o tráfico; indagado sobre o que a pessoa que levou à viatura falou, respondeu que tal indivíduo afirmou que havia ido buscar droga e que o cidadão abordado por seu parceiro estava efetuando o tráfico de drogas no local; indagado sobre como chegaram em tal indivíduo e se o viram comprando alguma coisa, respondeu que eles estavam próximos, de cinco a dez metros, sendo que estavam apenas os dois indivíduos naquele local em que o avistaram; quando fez a abordagem à testemunha, o réu fugiu por cerca de 200 metros, chegando a um terreno ao lado do lixão, onde ficam alguns usuários; perguntado se a testemunha que abordou disse que havia ido buscar droga especificamente com EDVAN, respondeu que indagou à testemunha se o réu é quem iria vender droga à ela, tendo referido indivíduo respondido "Isso, eu estava conversando com ele".

A testemunha Jean Victor Hiroshi Ioshimura, policial militar, disse que estavam em patrulhamento pelo complexo Santa Clara e viram dois indivíduos parados na esquina da Rua Newman com a Rua 02; no momento em que foram abordá-los, um indivíduo ficou no local e o outro saiu correndo; foi ao encalço do indivíduo que fugiu e, em dado momento, chegando próximo a um terreno na Avenida Gerônimo de Camargo, o réu jogou uma sacola, a qual caiu ao solo, sendo que algumas drogas se espalharam pelo local; foi necessário uso de força, sendo que também foi ao solo; indagado sobre o que fazia com a droga, o réu disse que era usuário e que pegou a sacola porque estava perto dele, porém, naquele horário, não ficam muitas pessoas no local, pois eram três horas da manhã; indagado se além do réu e do suposto usuário detido juntamente com o réu, havia mais alguém no local em que os visualizaram no primeiro momento, que pudesse ser dono da sacola, respondeu que não; indagado se naquele primeiro momento o réu já estava com a sacola na mão, respondeu que estava e que se tratava da mesma sacola que ele jogou durante a fuga; indagado sobre a distância que havia entre o réu e a outra testemunha levada à Delegacia, respondeu que estavam distantes quatro ou cinco metros; confirmou que o outro indivíduo foi levado à Delegacia também e afirmou que era usuário de drogas e estava indo ao local para comprar entorpecente; ao perguntar se tal indivíduo conhecia o réu, salvo engano, ele respondeu que já havia comprado drogas do acusado; indagado se a testemunha confirmou que foi ao local comprar drogas de EDVAN, respondeu que sim; indagado se se recordava das drogas apreendidas, afirmou que havia uma quantidade de maconha, crack e cocaína, esta última em quantidade um pouco maior.

Pois bem.

O réu, em solo policial, alegou que estava no local apenas para comprar drogas para si mesmo e para seus amigos (ação última que, por si só, já caracterizaria o tráfico, se verdade fosse).

Ocorre que em juízo, o réu apresentou versão absolutamente diferente, narrando que brigou com a mãe de sua filha, em Minas Gerais, e veio para Atibaia. Disse que bebeu durante o dia e, já na madrugada, foi para a região do Santa Clara, numa "biqueira".

Alegou que em dado momento, uma viatura surgiu, sendo que os policiais passaram correndo atrás de dois indivíduos. Afirmou ter saído despreocupadamente em sentido contrário, pois não estava vendendo drogas, muito embora já tivesse adquirido 24 pedras de crack.

Afirmou, então, que um policial veio por trás lhe apontando a arma, dando ordem de

prisão. Segundo sua narrativa, tal policial chamou outro agente pelo rádio. Em seguida, o acusado disse que foi espancado com socos e pontapés em seu rosto. Negou qualquer relação com os demais entorpecentes, os quais afirmou que só foram apresentados na Delegacia, disse que restaram R\$ 69,00 dos R\$ 320,00 que trouxe consigo de Minas Gerais e que não conhecia a testemunha Wellington.

A divergência de narrativas apresentadas por parte do réu é considerável.

Em solo policial, não apresentou qualquer detalhe a respeito da ocorrência, tendo dito que apenas havia ido buscar entorpecentes para si próprio, bem como para amigos.

Em juízo, optou por apresentar detalhes que não comprovou, como a alegada briga que teve com a mãe de sua filha em Minas Gerais – o que teria motivado sua vinda à Atibaia. E não comprovou tal alegação porque nas informações sobre sua vida pregressa, o réu assumiu residir em habitação coletiva, localizada em Atibaia, classificando-se como morador de rua, o que é perfeitamente observável às fls. 17, 19, 29 e em seu próprio termo de interrogatório, acostado às fls. 08.

Assim, tal narrativa, segundo a qual o réu teria vindo de Extrema para Atibaia naquela data, para beber e usar drogas, por ter brigado com a mãe de sua filha, não se comprovou, uma vez que o réu assumiu que reside em Atibaia em todos os outros momentos processuais.

Além disso, sua alegação de que “apenas” comprou 24 porções de crack e que não tinha relação alguma com os demais entorpecentes (os quais alegou terem surgido tão somente em solo policial), restou infirmada pelo seguro depoimento dos agentes policiais.

O policial Carlos relatou que, durante patrulhamento pela região, avistaram dois indivíduos, tendo desembarcado da viatura para efetuar a abordagem de um deles, o usuário Wellington, enquanto seu parceiro partiu em direção ao outro indivíduo, que fugiu correndo por cerca de 200 metros.

A testemunha esclareceu que após efetuar busca pessoal em Wellington, foi atrás de seu parceiro, que se encontrava ao solo com o rapaz que ele havia abordado. Afirmou ter visto várias porções de maconha, crack e cocaína jogadas no chão, sendo informado por seu parceiro que, durante a fuga, o indivíduo dispensou a sacola com drogas, a qual se abriu, espalhando os entorpecentes.

Carlos ainda confirmou que já abordou o réu algumas vezes e que Wellington, ao ser questionado, afirmou que havia ido buscar droga e que o réu, abordado por seu parceiro, estava efetuando o tráfico no local.

Jean, parceiro da testemunha Carlos, apresentou narrativa linear, esclarecendo que foi atrás do réu durante a fuga. Em dado momento, chegando próximo a um terreno na Avenida Gerônimo de Camargo, viu o instante em que o acusado jogou uma sacola, a qual caiu ao solo, sendo que algumas drogas se espalharam pelo local.

A testemunha confirmou ter utilizado de força para conter o acusado, motivo pelo qual também foi ao solo. Confirmou, ainda, que a sacola encontrada foi a mesma arremessada pelo réu durante a fuga.

Por fim, a testemunha ainda asseverou que o outro indivíduo, Wellington, afirmou que era usuário de drogas e estava indo ao local para comprar entorpecente, sendo que, salvo engano, tal testemunha chegou a afirmar que já havia comprado drogas com o acusado.

Ambas as testemunhas policiais esclareceram que o réu e referida testemunha estavam aproximadamente cinco metros distantes um do outro, no momento do início da abordagem, e que apenas os dois indivíduos estavam no local.

Com efeito, o relato dos policiais confere com a narrativa de Wellington em solo policial, acostada às fls. 07, oportunidade em que referida testemunha confirmou que é usuário de entorpecentes, que estava no local para comprar drogas com o réu e que o conhece pela alcunha de “Neguinho”, tendo confirmado que já havia comprado entorpecentes com o acusado anteriormente.

Wellington narrou que durante a abordagem, “Neguinho” saiu correndo e foi alcançado pelos policiais. Disse que, ao ser abordado, ainda não havia comprado a droga.

Como se pode observar, tal relato justifica a distância que havia entre acusado e testemunha: Wellington ainda não havia comprado o entorpecente, sendo que se aproximava do réu justamente para adquirir drogas com ele, a quem conhecia por

"Neguinho" e de quem já havia adquirido drogas anteriormente. Com a chegada da polícia, Wellington disse que foi abordado e que o réu fugiu. Há completa coerência entre o depoimento dos policiais ouvidos e o de referida testemunha, quando ouvida em solo policial.

Em juízo, entretanto, Wellington decidiu inovar.

Alegou que não conhecia o rapaz que foi preso e que foi obrigado, pelos dois policiais, a dizer o que disse na Delegacia. Narrou que o réu estava em outro lugar, com outro policial, enquanto estava quatro ruas acima, onde há uma "biqueira".

Ao ser confrontado com a falta de coerência em os policiais procurarem, a quatro ruas de distância, alguém para incriminar gratuitamente, a testemunha disse não saber se os policiais saíram atrás de qualquer pessoa.

E foi além: ao ser indagado sobre quem estava na sala, por ocasião de sua oitiva em solo policial, afirmou, inicialmente, que só havia o "rapaz do computador".

Novamente confrontado com o absurdo da situação, pois considerando-se que só o escrivão o acompanhava e que poderia, dessa forma, apresentar qualquer versão que não aquela narrada, a qual obviamente incriminou o réu, mudou de narrativa, alegando que estavam na sala os dois policiais e o "rapaz do computador".

É evidente que a testemunha, visando evitar comprometimento com traficante de drogas, optou por faltar com a verdade em juízo, sendo certo que em solo policial, apresentou depoimento que se mostrou absolutamente linear aos relatos apresentados pelos agentes ouvidos.

Quanto aos agentes da Lei, é conveniente rememorar que os depoimentos judiciais de guardas municipais e policiais, sejam civis ou militares, têm valor igual aos depoimentos de quaisquer outras testemunhas estranhas aos quadros da polícia, sendo descabido eventual preconceito acerca de seus testemunhos.

Inexiste qualquer impedimento ou suspeição nos depoimentos judiciais que sejam prestados por guardas municipais ou policiais, civis ou militares, mesmo porque seria um contrassenso o Estado, que outrora os credenciara para o exercício da repressão criminal, outorgando-lhes certa parcela do poder estatal, posteriormente, quando os chamassem à prestação de contas perante o Poder Judiciário, não mais lhes conferisse a mesma credibilidade no passado emprestada.

Inexiste, ainda, qualquer impedimento ou suspeição, no Código de Processo Penal, que faça desmerecer, em princípio, depoimentos provenientes de guardas municipais e policiais, civis ou militares, sendo inconstitucional qualquer entendimento que retire valor, a priori, dos depoimentos dos agentes da Lei, pelo simples fato de emanarem de pessoas revestidas de tal qualidade.

Neste sentido:

"O valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em Juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos" (STF-HC 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello - DJU 18.10.96, p. 39.846).

Assim, a prova colhida a partir dos depoimentos lineares e complementares dos agentes de segurança ouvidos, aliada aos depoimentos colhidos em solo policial, especialmente da testemunha Wellington, que confirmou, na Delegacia, ter ido ao local adquirir entorpecentes com o réu, de quem já havia adquirido drogas anteriormente, além da quantidade de drogas encontradas com o réu, demonstrou firmemente a autoria do delito de tráfico por parte do acusado, que apresentou versões distintas ao ser ouvido na Delegacia e em juízo, ocasiões em que, diga-se, não comprovou quaisquer de suas versões.

Além disso, o depoimento judicial de Wellington se mostrou falacioso, conforme análise supra, que demonstrou as incoerências verificadas, além de ato falho praticado pela testigo, ao afirmar, inicialmente, que prestou seu depoimento

somente perante “o rapaz do computador”, corrigindo-se, ao ser confrontado com a falta de lógica envolvida na situação, para dizer que estavam, na sala, os policiais que o detiveram e o “rapaz do computador”.

Desta forma, não há como se cogitar a absolvição do acusado.

E não há como defender a desclassificação do delito de tráfico para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06.

O artigo 33, da Lei 11.343/06, não define como necessário, para a consumação das figuras típicas em questão, o caráter comercial do tráfico. Aliás, sequer delimita qualquer definição para “traficante”, limitando-se a descrever figuras típicas que, praticadas, ensejam penalidade.

In verbis:

“Art. 33. Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar: Pena - reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa” (Lei nº 11.343 de 23 de agosto de 2006).

Optei por destacar, na transcrição acima, justamente as condutas descritas na denúncia, as quais foram perpetradas pelo réu, bem como o restante do dispositivo, restando evidenciado que não há, na Lei, qualquer menção sobre a necessidade de se evidenciar a finalidade mercantil do entorpecente.

A ação descrita no artigo 28, da Lei 11.343/06, dispõe que “Quem adquirir, guardar, tiver em depósito, transportar ou trazer consigo, para consumo pessoal, drogas sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar (...)” (destaquei e grifei), estará sujeito às sanções previstas naquele dispositivo.

Este artigo, sim, aponta uma finalidade específica: o consumo pessoal. Assim, a comprovação de que a droga era destinada ao consumo pessoal cabe àquele que assim alega, conforme a regra estampada no artigo 156, do Código de Processo Penal. O réu não se desincumbiu de tal ônus, não tendo formado mínima prova a respeito do alegado consumo de drogas que fazia.

E ainda que o réu comprovasse algum consumo de entorpecentes – o que não fez, repiso –, é comum que o usuário do entorpecente faça do tráfico a fonte de sustento de seu vício. Assim sendo, ainda que o réu houvesse comprovado algum consumo de entorpecente, o fato é que uma atividade não exclui a outra. E as circunstâncias em que o acusado foi flagrado, bem delineadas pelas testemunhas agentes de segurança pública, não denotam se tratar, o réu, de mero usuário, mas sim de praticante do tráfico ilícito de entorpecentes.

Os laudos periciais acostados ao processo, às fls. 83/84, 86/87 e 89/90, apontaram a apreensão de “(...) invólucro(s) plástico(s) fechado(s) por aquecimento encerrando porção de material sólido particulado (...)”, cuja massa bruta somou 119,5 gramas, em que se detectou a substância cocaína (fls. 83), “(...) microtubo(s) plástico(s) dotado(s) de tampa própria encerrando porção de material sólido petrificado (...)” cuja massa bruta somou 19,2 gramas, em que se detectou a substância cocaína (fls. 86) e (...) invólucro(s) plástico(s) encerrando porção de fragmentos vegetais ressequidos, constituídos de folhas, folíolos, inflorescência, caules e frutos (...)”, cuja massa bruta somou 115,9 gramas, em que se detectou a substância tetrahydrocannabinol (fls. 89), todas substâncias de uso proscrito no Brasil.

Cumpra esclarecer que o crack é produzido a partir dos restos do refino da cocaína, que, por sua vez, é produzida a partir de uma pasta-base. O crack, portanto, não é substância autônoma, mas sim subproduto da cocaína. Logo, é certo que o laudo de exame químico-toxicológico, ao analisar o crack, atestará a presença de cocaína. É o quanto basta para restar caracterizada a prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Reconhecida a autoria, passo a dosar a pena.

Na dosagem da pena devem ser levadas em consideração as diretrizes do art. 59 do Código Penal. No entanto, nos termos do art. 42 da Lei 11.343/06, o juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do

Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente.

O réu ostenta duas condenações pretéritas ensejadoras de reincidência, de modo que uma lhe onerará como reincidência propriamente dita e a outra em forma de maus antecedentes. Desta forma, utilizo a condenação estampada na certidão de fls. 47/48, referente ao processo 7950-28.2014.8.26.0048, pela prática de delito de tráfico de entorpecentes, cuja sentença transitou em julgado aos 01 de agosto de 2017, como forma de reconhecer-lhe maus antecedentes.

Neste sentido:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ESPECIAL. DESCABIMENTO. RECENTE ORIENTAÇÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL E DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. IMPETRAÇÃO ANTERIOR À ALTERAÇÃO DO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. ANÁLISE DO ALEGADO CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NECESSIDADE. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO PELA DIMINUIÇÃO DA REPRIMENDA. PENA-BASE FIXADA ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. EXISTÊNCIA DE CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. POSSIBILIDADE. CONDENAÇÕES JÁ TRANSITADAS EM JULGADO. MESMA CIRCUNSTÂNCIA DE AGRAVAMENTO DE PENA CONSIDERADA DUAS VEZES. FASES DISTINTAS DE APLICAÇÃO DA PENA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. PRECEDENTES. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DA PERSONALIDADE. JUÍZO NEGATIVO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 444/STJ. QUANTUM DE AUMENTO EM RAZÃO DA REINCIDÊNCIA. MAJORAÇÃO EXCESSIVA. (...) 4. É pacífica a orientação deste Tribunal Superior no sentido de que, a existência de circunstâncias judiciais desfavoráveis, autoriza a fixação da pena-base acima do patamar mínimo. 5. Este Sodalício orienta que não configura bis in idem ou inconstitucionalidade, quando, reconhecidas múltiplas reincidências, o sopesamento, na fixação da condenação, de uma na primeira fase, para exasperar a pena-base pelos maus antecedentes (art. 59, CP), e de outra na segunda fase, como circunstância agravante (art. 63, CP) (...).” (STJ - HC: 215126 MS 2011/0183443-9, Relator: Ministro CAMPOS MARQUES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PR), Data de Julgamento: 18/04/2013, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 24/04/2013) (destaquei).

No mais, culpabilidade normal à espécie, nada tendo a valorar. Pouco se colheu a respeito de sua conduta social e personalidade. Quanto aos motivos do crime, os comuns ao tráfico. Quanto à natureza e quantidade do produto, foram apreendidas 102 porções de cocaína, 67 porções de maconha e 24 pedras de crack. A quantidade e a variedade de entorpecentes apreendida é razão suficiente para que a conduta seja exemplarmente repreendida (artigo 42, Lei 11.343/06).

Sobre o tema, pronunciou-se Guilherme de Souza Nucci: “(...) não é demais ressaltar que a natureza e a quantidade da substância (entendendo-se o material utilizado para o preparo da droga) ou do produto (a droga produzida de algum modo) fazem parte das circunstâncias e das consequências do crime, elementos também constantes do art. 59 do Código Penal (...) A Lei de Drogas baseia-se, principalmente, na punição de crimes de perigo abstrato, o que significa destacar, como elementos preponderantes na individualização da pena, dentre outros, a natureza e a quantidade da substância ou do produto. É natural supor que quanto maior for a quantidade de drogas ilícitas em circulação, maior será o perigo em relação à saúde pública. Ademais, quanto mais forte for a droga ilícita, igualmente, mais grave será a consequência em virtude de sua utilização” (Leis Penais e Processuais Penais Comentadas 6ª ed. - São Paulo: RT 2012 v. 1 p. 287).

Assim, considerando as circunstâncias judiciais desfavoráveis apontadas, fixo a pena-base acima do mínimo legal, em 06 anos de reclusão, e 600 dias-multa, diária mínima, uma vez que o réu está preso. O valor total da pena de multa deverá ser atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

Na segunda fase de dosimetria, incidem as agravantes relativas à reincidência (artigo 61, I, do Código Penal) e o fato de o réu ter cometido o crime em ocasião de calamidade pública (artigo 61, inciso II, alínea “j”). O réu é reincidente, haja vista a condenação estampada na certidão de fls. 46/47 dos autos, referente ao processo 0000262-08.2016.8.26.0545, que também versou sobre tráfico de entorpecentes, cujo trânsito em julgado da sentença condenatória ocorreu em 14 de novembro de 2017, não tendo havido o decurso do prazo depurador de cinco anos entre tal condenação e a nova prática delitiva. Além disto, o crime foi praticado durante



a vigência de estado de calamidade, o qual foi decretado em março de 2020, não havendo que se discutir ter o réu se beneficiado ou não da condição para a prática delitiva, uma vez que a Lei não faz tal distinção. A pena é agravada, e atinge o patamar de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, além de 720 dias-multa. Na terceira e última fase da dosimetria penal, não há causas de aumento de pena. Considero incabível o reconhecimento da causa de diminuição prevista no parágrafo 4º do artigo 33 da Lei 11.343/06. O réu é multi reincidente específico, o que impede objetivamente a concessão do benefício.

Destarte, a pena definitiva é fixada em 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, além de 720 dias-multa.

O regime inicial para cumprimento de pena será o fechado, considerando o fato de que se trata de réu reincidente, que ostenta circunstâncias judiciais absolutamente desfavoráveis,

Além disto, de se considerar que o tráfico de entorpecentes é das atividades mais danosas ante o seio social hodierno. Sua prática atinge diretamente direitos e garantias fundamentais das pessoas, além de fomentar outros tipos de atividades ilícitas. Causa, ainda, direta e indiretamente, considerável mobilização estatal, atingindo, por consequência, o erário público, que tem de arcar com as custas de policiamento ostensivo, seja preventivo ou repressivo, campanhas de conscientização – sobre o óbvio, diga-se –, tratamento de saúde aos adeptos do uso contumaz, dentre outras inúmeras situações relacionadas, as quais requerem pronta ação do Estado. Isto, entretanto, custa dinheiro e onera o contribuinte.

Seria um contrassenso o mesmo Estado que luta para combater tão nefasta prática – a tão altos custos – permitir que seu principal responsável retorne à liberdade sem experimentar a necessária punição e, principalmente, sem que de seu ato se arrependa, sobre ele reflita e o corrija, podendo criar, em última análise, a aplicação de regime mais brando, verdadeira sensação de impunidade, capaz, inclusive, de ensinar ao condenado mais um motivo para que torne à rentável prática.

Nem se diga haver o pequeno traficante, sobre quem recairia todo o peso da mão Estatal, e o grande traficante, que se ocultaria na hierarquia da coalizão narcotraficante, como tentativa de justificar atos injustificáveis. A Lei coíbe o tráfico e este existe por duas razões: porque alguém consome o produto e porque alguém o vende – eis a figura daquele que trafica, independentemente de sua posição hierárquica.

A ação do indivíduo encarregado de disseminar a substância entorpecente – geralmente identificado como o “pequeno traficante” – deve ser entendida como parte integrante e crucial do conjunto responsável pela narcotraficância: é ele que, por meio de sua ação, viabiliza o comércio “varejista” das drogas, fomentando o consumo e a própria continuidade da produção de entorpecentes, consubstanciando, sua atividade, não só o meio de sustento próprio, mas de toda a cadeia criminoso ligada ao narcotráfico – prática delitiva que domina a maior parte dos debates sobre segurança pública e que consiste, em verdade, no cerne financeiro das atividades criminosas em geral.

É do espírito da Lei combater o tráfico ilícito de entorpecentes, seja ele praticado pelo iniciante – a quem é conferido algum tipo de benefício, conforme se observa do parágrafo 4º do artigo 33, Lei 11.343/06 – pelo gerente de “boca” ou por associados a organizações criminosas – pessoas a quem a Lei trata de maneira especial e mais severa.

O fato é que o tráfico, independentemente do tipo de atuação de seu praticante, merece reprimenda exemplar.

Sobre todo o tema até então debatido, uma brilhante manifestação oriunda do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo:

“(…) Não se olvide da recente decisão do Colendo Supremo Tribunal Federal, reconhecendo, em caráter incidental, a inconstitucionalidade do § 1º do artigo 2º da Lei de Crimes Hediondos, que estabelece o cumprimento da pena em regime inicialmente fechado, aos agentes condenados por crimes hediondos e equiparados (STF, 111.840/ES, Relator Ministro DIAS TOFFOLI, julgado de 27-06-12), todavia, a norma citada está em pleno vigor e a recente decisão da Suprema Corte não impõe de

forma obrigatória o acatamento do novo entendimento. Registra-se ainda que o Excelso Supremo Tribunal Federal recentemente também reconheceu, de modo incidental, a inconstitucionalidade da expressão “vedada a conversão em pena restritiva de direitos” constantes dos artigos 33, § 4º e 44 da Lei Antidrogas. Esse reconhecimento de inconstitucionalidade, todavia, não implica substituição automática da pena de prisão por pena restritiva de direitos. Na decisão é ressalvada a possibilidade de o julgador analisar, em cada caso concreto, a viabilidade e admissibilidade dessa substituição. Tal como veiculado de forma contínua nos diários de grande circulação no país, o tráfico de drogas vem se tornando assustadoramente contumaz no cotidiano das grandes, médias e até mesmo pequenas cidades, inclusive aquelas incrustadas nos mais distantes rincões da nação. Não há distinção entre ricos ou pobres, raça ou religião; o comércio ilegal avança de forma incontrolável, ora favorecido pela insuficiência policial, ora beneficiado pelo abrandamento do rigor penal. Evidentemente o grande traficante, o responsável pela distribuição da droga em determinada região ou cidade, não se envolverá diretamente na comercialização da droga; valer-se-á do jovem preterido pela sorte, disposto a lutar por algum dinheiro que propicie a imediata realização de necessidades básicas. Ocorre então a perfeita comunhão de interesses. De um lado, o responsável pelo tráfico, que se arrima em incautos jovens, inimputáveis pela tenra idade, ou de passado até então escorreito, para comercializar seu produto, e de outro o pequeno cidadão que, eventualmente detido pela prática espúria, poderá ser beneficiado com a substituição da pena privativa de liberdade pela pena restritiva de direitos. O número expressivo de pessoas que poderiam ser servidas com as drogas, bem demonstra a periculosidade latente do réu, recomendando o cumprimento da pena no regime inicial fechado e obstando a substituição da pena por quaisquer das medidas alternativas. Portanto, acolho a pretensão do representante do Ministério Público e fixo o regime fechado para início do cumprimento da pena, tendo em vista que se trata do regime compatível com a conduta do acusado. Cumpre ressaltar ainda que as circunstâncias dos autos, a meu sentir, data máxima vênia, obstam a ingenuidade do reconhecimento de que se tratava de pequenos traficantes, mesmo porque esta simplória qualificação é permeada por um revés de complexidade. Qual a equação para se distinguir o grande traficante do pequeno comerciante? A quantidade de drogas apreendidas no momento da prisão? A constância da atividade do comércio ilegal? Cabe aqui outra indagação: não parece pouco provável que o grande traficante irá se aventurar a permanecer em um ponto de venda de entorpecentes, correndo riscos desnecessários, quando poderá se valer daquelas pessoas a quem a norma legal classifica como o pequeno traficante? A meu ver, e volto a repetir, sempre respeitando os posicionamentos em sentido contrário, quando se atribui ao infrator a condição de pequeno traficante, estar-se-á procurando combater sempre o efeito e não a causa de tão perverso delito, haja vista que aquele indivíduo considerado como o grande traficante dificilmente será detido, porque sempre contará com os préstimos do pequeno traficante. Não se pode ignorar também que o tal pequeno infrator, beneficiado por esta qualificação com pena menos rigorosa, na maioria das vezes, voltará a reincidir na empreitada criminosa, pois a tal atividade delituosa basta a lhe proporcionar, sem maiores esforços, rendimento financeiro que raros cidadãos de bem chegam a alcançar em algum momento de suas vidas. E a consequência desta fartura financeira é previsível, ante a frouxidão do rigor penal, data máxima vênia, que de algum tempo a esta parte tem levado à concessão do regime aberto, e até mesmo à substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direito, ao traficante de drogas, com o intuito óbvio de amenizar as amarguras do cidadão castigado pela incompetência do Estado, que, de forma implícita, os induz a lançar mão de meios espúrios para a sua sobrevivência. Entretanto, em que pese ser louvável o sentimento de humanidade, sobretudo com as pessoas mais preteridas pela sorte, não se pode olvidar o resultado funesto desta benesse, ou seja, a destruição de vidas, de laços familiares, da paz social, e o inquestionável incremento de delitos permeados de igual gravidade, ora por necessidade da obtenção de meios materiais para a satisfação da dependência química, ora diante da inconsciência, da inimputabilidade, causada pela droga, a tal ponto de levar uma pacata pessoa ao

extremo de uma atitude inimaginável a um ser humano. Devo reconhecer que tenho sido voto vencido junto a meus pares, a cujos posicionamentos me curvo com a humildade esperada, e por isso mesmo, eventualmente, sou reconhecido como extremamente rigoroso, entretanto, não o faço como castigo, o que seria de todo despropositado e bem acarretaria o desvirtuamento da finalidade da pena. É imperativo ressaltar também que não tenho a menor intenção de negar vigência à norma legal ao não aplicar na maior parte das vezes - como Relator dos autos aos meus cuidados - o redutor previsto na Lei nº 11.343/06, mas entendo que a tanto é imprescindível a comprovação de que o agente também conte com algumas qualidades que devem permear a conduta do cidadão de bem, v.g., a participação efetiva de atividade escolar ou o exercício de trabalho lícito remunerado, e só assim, mas ainda com muito esforço, conseguiria visualizar a figura do pequeno traficante. (...)” (APL TJ-SP 0027320-18.2012.8.26.0224; Órgão Julgador: 4ª Câmara Criminal Extraordinária; Publicação: 18/01/2017; Julgamento: 14 de Dezembro de 2016; Relator: Cesar Augusto Andrade de Castro).

Salutar a fundamentação, que reduz a termo o espírito buscado pela construção normativa do Legislador. É razão mais que suficiente para que se entenda que o praticante do tráfico de drogas deve permanecer afastado do convívio em sociedade. Ficam vedados, ainda, pelas mesmas razões, quaisquer outros benefícios, incluindo-se a substituição da pena restritiva de direitos em privativa de liberdade, pelas razões acima apontadas, tudo a indicar não ser referida conversão medida adequada e suficiente ao caso concreto.

Assim é que se decide.

Centrada nestes fundamentos, JULGO PROCEDENTE a ação penal e condeno EDVAN DE BRITO FARIAS, vulgo “Neguinho”, como incurso nas penas do artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/06, combinado com o artigo 61, inciso II, alínea “j” (calamidade pública) do Código Penal, à pena de 07 anos, 02 meses e 12 dias de reclusão, em regime fechado, além de 720 dias-multa, diária mínima, com valor total da pena de multa atualizado nos termos do art. 49, § 2º, do Código Penal.

O réu está preso e assim deverá permanecer, já que foi preso em flagrante e permaneceu recolhido por todo o processo, não sendo razoável, agora que foi condenado, ser colocado em liberdade, ainda mais diante do fato de ter praticado conduta de extrema gravidade, nos termos acima fundamentados. A prática exige punição exemplar. Ademais, é réu multirreincidente, não havendo qualquer segurança ao juízo de que, uma vez em liberdade, não acabe retomando a atividade que ensejou seu encarceramento. Recomende-se o réu na prisão em que se encontra.

Transitada esta sentença em julgado, comunique-se a presente condenação à Justiça Eleitoral em atenção o artigo 15, inciso III, da Constituição Federal.

Decreto a perda, em favor do FUNAD, do valor em dinheiro apreendido nos autos, uma vez não comprovada a sua origem lícita. Após o trânsito em julgado, oficie-se para levantamento.

Por último, condeno o réu ao pagamento das custas equivalentes a 100 UFESP's, nos termos do artigo 4º, inciso III, item 5, § 9º, alínea “a” da Lei nº 11.608, de 29 de dezembro de 2003. Defiro ao réu os benefícios da gratuidade da Justiça.

Por fim, extraia-se cópias das principais peças dos autos e da gravação do depoimento prestado pela testemunha Wellington Garcia Doratiotto, encaminhando-as à Autoridade Policial, para fins de eventual instauração de Inquérito para apuração de crime de falso testemunho.

P.I.C.

Atibaia, 11 de março de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA